

1502684-81.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, em 2021. Sua confissão encontra eco nos autos. De fato, ouvido em juízo, Ricardo Alexandre Pinheiro, policial militar, afirma que o local é conhecido ponto de tráfico; que, quando adentraram na via, viram o réu mexendo em um monte de areia, que estava coberto com o plástico preto; que ele, ao ver a viatura, saiu andando; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1502684-81.2021.8.26.0616Ré(u):Weslen Moraes de Souza

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502684-81.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336388/2021

- DEL.POL.SUZANO, 21880631 - DEL.POL.SUZANO, 4703/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2336388-

26.2021.030309 - DEL.POL.SUZANO, 2336388 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weslen Moraes de Souza

Réu Preso

Em 26 de julho de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Weslen Moraes de Souza e seu Defensor Dativo nomeado DR(A). Hernandes Tassini OAB 229466/SP. Presentes as testemunhas Comuns: Ricardo Alexandre Pinheiro e Paulo Cesar Diniz Arrais. Iniciados os trabalhos, pelo D. Promotor de Justiça foi apresentado o seguinte aditamento à denúncia: A fim de corrigir erro material, apresento, nos moldes do art. 569 do Código de Processo Penal, aditamento para que conste, nos fatos, como drogas que o réu ocultava: 32 porções de "maconha", 11 porções de cocaína, 15 de crack e 03 frascos de lança-perfumes. Em seguida, pelo D. Defensor

foi dito que não se opunha ao recebimento do aditamento. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: recebo o aditamento à denúncia. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: Paulo Cesar Diniz Arrais e Ricardo Alexandre Pinheiro. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu Defensor, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: O réu WESLEN MORAIS DE SOUZA foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 07h10, na Rua Florentino do Nascimento, 280, Jardim Nova América, nesta cidade e Comarca de Suzano, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, nas imediações de sede de entidade social, cultural, recreativa e beneficente, serviço de reinserção social, e local onde se realiza diversão de qualquer natureza, 32 (trinta e duas) porções de cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 77,21g, e 11 (onze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 5,55g, 16 (dezesesseis) porções de crack, subproduto da cocaína, pesando aproximadamente 2,22g, 03 frascos de lança-perfumes, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Do relatório. A denúncia foi aditada para inclusão da causa de aumento (fls. 124). O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar a fls. 134/136. A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 140/141). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado. É o breve relatório. Das provas. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Segundo o apurado, o réu deliberou por praticar tráfico de drogas. Assim foi que, quando do ocorrido, no momento em que estava em pleno exercício da atividade ilegal, foi ele surpreendido por policiais militares, os quais, em diligências pelo local, em atenção à denúncia anônima, o avistaram guardando uma sacola plástica embaixo de um saco preto que estava cobrindo areia para construção. Efetuada a abordagem do réu, em revista pessoal, foi localizado em seu poder uma porção de crack e um celular e, na sacola que ele ocultava quando surpreendido, foram encontradas as drogas acima mencionadas (07 porções de maconha e 23 de cocaína), as quais eram mantidas guardadas e em depósito, para pronta entrega a consumo de terceiros, bem como, dentro de um estojo, a quantia de R\$ 14,00, produto da traficância. Os fatos acima narrados, ao final da instrução, restaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação (fls. 40/43), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/74), laudo pericial de objeto (fls. 110/112), laudo do local (fls. 106/109), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, de igual modo, é incontestável. Ouvido formalmente perante a Autoridade Policial, o réu confessou a traficância, afirmando que recebia R\$ 20,00 toda vez que guardava as drogas naquele local, para que o "vapor" - um indivíduo de apelido "menor" - as vendesse (fls. 23). Em juízo, o réu é novamente confesso. Afirma que realmente guardava as drogas no local; que as guardou lá para outro moleque vender; que fez isso porque passava necessidade; que o local é próximo de um salão de festas e uma escola; que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, em 2021. Sua confissão encontra eco nos autos. De fato, ouvido em juízo, Ricardo Alexandre Pinheiro, policial militar, afirma que o local é conhecido ponto de tráfico; que, quando adentraram na via, viram o réu

mexendo em um monte de areia, que estava coberto com o plástico preto; que ele, ao ver a viatura, saiu andando; que o abordaram e encontraram drogas; que, indagado, o réu afirmou que havia sido contratado apenas para deixar as drogas ali para o tráfico; que, pelo que se recorda, era cocaína e crack; que no local havia apenas o réu. Na mesma linha são as declarações da também policial militar Paulo Cesar Diniz Arrais, que destaca ainda que como réu foi encontrado um pino de crack e um celular. Asseverou que no monte de areia foram apreendidas as demais drogas e que o réu alegou que havia recebido R\$ 20,00 para deixar a droga lá, para que um menor as vendesse posteriormente. Como se vê, não bastasse a confissão, as declarações dos agentes da força pública, somadas às comprometedoras circunstâncias que permeiam a detenção do acusado, demonstram com segurança a posse das drogas e a finalidade mercantil. Nesse ponto, destaque-se para o fato de o réu ter sido preso exatamente no momento em que guardava uma sacola plástica embaixo de um saco preto que estava cobrindo areia para construção, no interior da qual foram encontrados os entorpecentes supra (32 porções de maconha, 11 de cocaína, 16 de crack e 03 frascos de lança-perfumes), bem como, dentro de um estojo, a quantia de R\$ 14,00, produto da traficância. Note-se, ainda, que a prisão dele e apreensão das drogas não foram casuais, mas em razão da apuração de denúncia anônima dando conta da traficância naquele local. Não por acaso, indagado, o acusado confessou a traficância. Não há nos autos qualquer elemento hábil a indicar que os agentes da lei tenham falseado a verdade e, por conseguinte, razão plausível para se afastar o valor probatório dos atos funcionais por ele praticado e dos coesos e seguros relatos testemunhais por eles emanados. As palavras dos policiais, por si só, não podem ser tidas como indignas de fé, uma vez que estes não estão impedidos de depor e, por consequência, hão de merecer total credibilidade, desde que não provada má-fé ou abuso de poder, o que vale dizer que a inidoneidade não pode ser genérica, mas sim específica e demonstrada em cada caso. E, na hipótese dos autos, tais testemunhas sequer foram contraditadas. Com efeito, a quantidade e variedade de entorpecentes e a forma como se encontravam acondicionado, aliados ao dinheiro apreendido, bem como a confissão formal do réu, demonstram que a droga se destinava ao tráfico. Portanto, a condenação do réu é de rigor. Da dosagem a pena. No que tange a dosimetria da pena, requer seja considerada a natureza e a quantidade das substâncias apontadas no laudo toxicológico, uma vez que o acusado foi detido com nada menos que 32 porções de maconha, 11 de cocaína, 16 de crack e 03 frascos de lança-perfumes. Assim, atendendo ao critério de preponderância estabelecido no artigo 42 da Lei n.

11.343/06 sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, requer-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na terceira fase, de rigor o cômputo da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, à vista do croqui de fls. 129, que demonstra ter o crime ocorrido nas imediações de sede de entidade social, cultural, recreativa e beneficente, serviço de reinserção social, e local onde se realiza diversão de qualquer natureza (20m da Congregação Brasil Cristão; 200m da Escola Municipal Isaias Martinelli Gama; 300m do Salão de festas Chácara Sonhos de Noiva - fls. 109), fato que evidencia maior censurabilidade da conduta. Embora tecnicamente primário, o réu ostenta condenação por tráfico de drogas recente por igual delito (fls. 45), o que evidencia sua dedicação à prática criminosa e, por conseguinte, a inviabilidade da redução de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas. No tocante ao regime de cumprimento de pena, o delito em questão é equiparado aos hediondos, conforme art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal. Deste modo, não bastasse a gravidade concreta (especialmente a quantidade e variedade de entorpecentes de alto poder viciante, próximo de estabelecimentos de maior dispersão no meio social), a ele será

dispensado o tratamento determinado pela Lei 8.072/90, a qual determina, em seu art. 2º, §1º, que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado. Pontua-se, ainda, que conforme determina o art. 44 da Lei 11.343/06, o crime em testilha é inafiançável e insuscetível de sursis. Dado a gravidade concreta (especialmente a quantidade e variedade de drogas em proximidade a locais de maior dispersão) e hediondez equiparada do delito, incompatível se mostra a conversão em restritivas de direitos. Do pedido. Diante do exposto, requeiro a condenação do réu nos termos da denúncia, como medida de Justiça. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram

apresentadas as seguintes alegações finais: Verte dos autos, que o denunciado no dia, horário e local, devidamente descrito na respeitável denúncia, fora surpreendido guardando e mantendo em depósito todas as substâncias entorpecentes elencadas na peça inaugural, e ao final fora preso em flagrante. Diante de tais circunstâncias, o réu fora denunciado como incurso no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso III (aditamento de fls. 124), ambos da Lei 11.343/06. O réu fora devidamente citado, apresentando defesa preliminar. Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas de acusação e de defesa, e o denunciado interrogado ao final. Em respeitáveis memoriais, o Douto Representante do Parquet, pugnou pela procedência da ação penal, aditando a peça acusatória para que assim o crime a que responde o denunciado seja agravado com o disposto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, lastreando seu respeitável entendimento na prova testemunhal constante nos autos. Essa a síntese do necessário. DA DEFESA. Do ponto de vista técnico é absolutamente sabido e correto que o réu se defende de fatos, ou seja, estando os fatos bem definidos na denúncia, destes o réu tenta se desvencilhar por intermédio das provas. No presente caso, a defesa discorda do respeitável entendimento do Douto Representante do Parquet, quanto a dosimetria da pena, bem como a eleição do regime inicial do cumprimento da reprimenda corpórea a ser aplicada no caso concreto, conforme veremos. Prefacialmente, há que considerarmos que no presente caso, o Defendido fora réu confesso, e nesse diapasão, em consonância com as demais provas encartas aos autos, é que iremos discorrer acerca da matéria, quer seja, acerca da dosimetria da pena propriamente dita. Deve-se considerar que o crime a que responde o defendido, quer seja, tráfico de drogas, concessa máxima venia, ser muito complexo, no qual conforme ficou comprovado em audiência de instrução, o denunciado era responsável pela guarda das substâncias entorpecentes. Data venia, cediço que naquele momento desesperador a que enfrentava o réu, quer seja, estando desempregado, estando em condição de morador de rua, ser usuário de substância entorpecente, se enveredou no nefasto mundo espúrio do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, isso deixando extremamente transparente no presente processo, quer seja, que o referido fora arrebatado pelo crime, devido suas condições pessoais absolutamente desfavoráveis. Humildemente entendemos que o denunciado, data venia, é uma vítima de um sistema cruel e desumano, que acaba por destruir a vida das pessoas, bem como famílias inteiras, denominado tráfico de entorpecentes. Não se desconhece que o denunciado ostenta maus antecedentes, e tal circunstância se presta a demonstrar efetivamente que a participação do referido no comércio espúrio de substâncias entorpecentes, ocorre justamente em razão do vício em drogas e demais circunstâncias. Nobre Julgador, por evidente que o denunciado infringiu um fato típico e antijurídico!!!! Não desconhecemos tais circunstâncias, mas nos indagamos: Será que o presente processo não está também envolvido por uma questão de saúde pública???? Sabedores de não ser este o papel do Poder Judiciário, mas que de toda sorte, dada a sensibilidade humana de cada pessoa, tais circunstâncias devem ser levadas em consideração, no momento da prolação da respeitável sentença. Por óbvio que pessoas em situação de rua, são consideradas mais vulneráveis, estando sujeitas ao aliciamento por parte do narcotráfico e organizações criminosas diversas atuantes em todos os segmentos de crimes. Atrela-se a tais circunstâncias, data venia, a situação aflitiva de instabilidade financeira e política que assola nosso país, principalmente em decorrência da pandemia por COVID 19, que lançou milhões de brasileiros a condição de extrema pobreza. Não são estes humildes argumentos que se prestam para conduzir o denunciado a absolvição, ou simplesmente canoniza-lo, nem tampouco justificar o crime que pesa contra o denunciado. Ao contrário, apenas estamos tentando demonstrar para Vossa Excelência, que atualmente nossa sociedade atravessa um momento de explosão dos índices de criminalidade, principalmente em relação aos crimes de roubos e tráfico de entorpecentes, mas que de toda sorte, mesmo com a elevação das penas dos crimes (como exemplificadamente o crime de roubo), bem como atuação forte do Poder Judiciário, não estão se prestando para coibir as práticas delitivas. Ora, em outra vertente, o que se mostra razoável dentro dos permissivos legais, é justamente que, o denunciado confessou a autoria delitiva; confessou a sua participação no crime; não fugiu em nenhum momento de suas responsabilidades, o

que por si, já representa o arrependimento do erro outrora cometido. Assim, entende a defesa, que o denunciado deve ter sua sanção corpórea atenuada com a confissão, conforme previsto no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal. Ainda, há que se observar que o denunciado na época do crime, era menor de 21 anos, assim devendo ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Acaso seja confirmada pelo juízo a condenação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (o que é provável, ante a expressa confissão em juízo), invoca a defesa a aplicação da hipótese penal privilegiada, prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Totalmente estranho ao mundo do crime, o acusado encontra-se extremamente arrependido da prática delitiva, tanto que assumiu suas responsabilidades confessando o crime. O acusado não representa ameaça à ordem pública ou à sociedade, é somente uma pessoa que em um momento de desespero, se enveredou no comércio espúrio de substâncias entorpecentes, mas que de longe pode-se afirmar que o mesmo seja voltado ao crime, o que entendemos, mas não sendo este o palco adequado para linha de argumentação, deveria ser submetido a um tratamento contra o vício de drogas, e não lançado à própria sorte no ergástulo. O pedido da defesa, destarte, visa confirmar a plena aplicabilidade do tráfico privilegiado ao caso concreto. Da dosimetria da pena e da fixação do regime. Primeira fase. O artigo 59 do Código Penal, em consonância com o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, estabelecem que, na fase de aferição das circunstâncias judiciais, o juiz deve, na fixação da pena, atentar para a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, conforme seja necessária para a reprovação e a prevenção do crime. Em nossos humildes entendimentos, consideramos que, em caso de procedência da ação penal, as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis ao réu, e nesse passo, a pena deve permanecer no mínimo legal. Ainda, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie. O réu é tecnicamente primário. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, é necessário transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval do Poder Judiciário. Analisando toda a situação fática do caso em apreço, não se encontra campo para acréscimo, uma vez que a quantidade apreendida está dentro dos padrões das apreensões normais e corriqueiras nesta comarca. O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito. Em outra vertente, caso Vossa Excelência entenda pela elevação da pena base, pugnamos que seja pela menor fração, em contrapartida observando o disposto na Súmula 444 do STJ. Segunda fase. No presente caso não existem causas agravantes. Contudo estão presentes as atenuantes, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea 'd', do Código Penal, o que pugnamos pela sua aplicabilidade. Terceira fase. Em que pese já termos apresentados argumentos acima, acerca do tema (tráfico privilegiado), mas levando-se em consideração o amor aos debates, mais uma vez frisamos: Na terceira fase da dosimetria da pena, há que se considerar a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo. Entendemos que obstar a aplicação do redutor, sob comento, é tornar letra morta a previsão legislativa que buscou estabelecer penalização diversa para as várias situações dos agentes presos ou envolvidos nos crimes de tráfico, afastando assim a indevida comparação entre aqueles que, por motivos diversos, se viram envolvidos nesse nefasto comércio espúrio de substâncias entorpecentes ou que nele estavam iniciando. Veja-se que versa de forma de penalização de forma diferenciada, observada a necessária e exigida individualização da pena. A quantidade de substâncias entorpecentes em si, não obsta a incidência do redutor requerido. As regras norteadoras previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, destinam-se a estabelecer parâmetros para a fixação das penas, como expressamente indicado no referido artigo, e não se confundem de forma alguma, com os requisitos exigíveis à aplicação do redutor. A causa de redução trazida pela Lei de Drogas se coloca como direito do réu e não faculdade do

julgador, se presentes estão os requisitos exigidos pela norma penal. Assim, no presente caso, considerando todas as circunstâncias dos autos, é de aplicar o redutor na fração de 2/3 (dois terços), até mesmo porque, trata-se de réu tecnicamente primário e não existe provas nos autos que o referido integre organização criminosa, fazendo assim, jus a concessão da benesse pleiteada. Dada toda as circunstâncias fáticas que envolvem o caso sob comento, entendemos que o denunciado, faz jus sim a aplicação do redutor legal, isso porque é possuidor dos requisitos objetivos previstos legalmente. O denunciado é tecnicamente primário, e as condições do fato que lhe é atribuído, em primeira análise é inerente ao tipo. Não pode a minorante requerida ser afastada, em apartada síntese sob o argumento de que os elementos constantes nos autos, revelam que o recorrente se dedicasse à atividade criminosa, pois trata-se de mera interpretação subjetiva e mais nada. Mais uma vez frisamos, que sequer ficou comprovado nos autos, que o denunciado integre uma organização criminosa. Quanto à quantidade de substâncias entorpecentes, devidamente suscitadas nos autos, data venia, em comparação com diversos outros tipos de casos semelhantes, o presente caso, versa de quantidade que pode ser considerada irrisória. A resposta estatal para casos que a envolvam deve ser temperada pelo § 4º, principalmente diante dos rigores do 'caput' do artigo 33, cuja pena mínima desponta absolutamente rigorosa e nada menos do que 05 (cinco) anos, tendo sido agravada em relação à revogada Lei nº 6.368/76, e demais leis posteriores. Não esquecer que a intenção legislativa foi no sentido de aplicar as agruras do traficante de primeira viagem, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, p. 782, Leis Penais e Processuais Comentadas, RT. Tal causa especial de redução é aplicada aos casos do 'Tráfico Ocasional', denominação cunhada pelo Prof. Luis Flávio Gomes, que deve ser interpretada pelo espírito da nova lei de drogas, que veio enrijecer o tratamento dado à traficância e ao mesmo tempo oportunizar à ressocialização aos pioneiros do tráfico. Não perder de vista que o legislador teve por intenção permitir a valoração da conduta dos envolvidos na cadeia de tráfico de acordo com a maior ou menor potencialidade lesiva das condutas, conferindo aos magistrados instrumento para diferenciá-los efetivando a verdadeira individualização constitucional. In caso, o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não deve ser ignorado pelo Douto Magistrado, eis que não atenderia aos requisitos legais. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, rogando a máxima venia, prequestionamos a matéria para interposição de eventuais recursos às Instâncias Superiores. No que pertine a qualificadora prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, data venia, em criteriosa análise do processo referenciado, especificadamente quanto ao laudo juntado aos autos, denota-se que não se pode presumir que a ação praticada pelo denunciado, teria grande risco de disseminação nas imediações das entidades mencionadas pelo dispositivo legal. Notadamente, a denúncia oferecida não apresenta qualquer razoabilidade ao considerar como imediações as circunstâncias descritas da suposta ocorrência de tráfico. Sobreleva pontuar que o termo “imediações” pressupõe proximidade do local, de modo que o objeto material seja mais facilmente distribuído ou oferecido. Embora não se exija a comprovação de que o sujeito traficava drogas diretamente com os frequentadores ou ocupantes destes locais, é imperioso que o crime de tráfico de drogas tenha ocorrido nas dependências ou imediações deles. Assim, a causa da majorante se daria exclusivamente em razão do lugar onde o tráfico é cometido, uma vez que serão seus frequentadores expostos ao risco inerente à atividade criminosa. A palavra “imediações”, bastante vaga, é assim definida por Vicente Greco: “O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura coibir: as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem” (Lei de Drogas Anotada –Lei 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 145). No caso sub judice, é forçoso considerar que a prática delituosa poderia facilmente atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem. Dessa forma, a

majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06 não deverá incidir sobre a prática delituosa atribuída ao denunciado. Esta, inclusive, é a posição da Egrégia 16ª Câmara de Direito Criminal, que assim entende: "TRÁFICO DE DROGAS. Apelo ministerial pretendendo a majoração da pena-base e a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Quantidade pequena de um só tipo de entorpecente apreendido com o réu. Imediações de quadras e UBS. Não comprovação de que o acusado se valia de suposta aglomeração de pessoas para a prática do tráfico. Afastamento mantido. Apelo defensivo pretendendo a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido para esse fim". TJSP; Apelação Criminal 0000643-98.2017.8.26.0571; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018. Ainda que o respeitável laudo pericial, devidamente encartado aos autos, ateste a presença de estabelecimentos suscitados nos arredores do local de prisão do réu, para incidência da majorante, insuficiente a proximidade física das instituições de que cuida o mencionado dispositivo. Afigura-se indispensável a demonstração de que o agente atuava com a intenção de propagar o uso de entorpecentes entre aqueles que circulam por tais lugares. Como não demonstrado que se buscava fornecer drogas aos frequentadores daqueles locais, a exasperação das penas a tal título representa consagração de responsabilidade penal objetiva, ferindo-se a garantia constitucional da culpabilidade em matéria criminal. Ensina Nilo Batista que: "o princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Não cabe, em direito penal, uma responsabilidade derivada tão-só de uma associação causal entre a conduta e um resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico. É indispensável a culpabilidade. No nível do processo penal, a exigência de provas quanto a esse aspecto conduz ao aforisma a culpabilidade não se presume". (Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, Revan, 1990, p. 104). Sabe-se que a mera proximidade geográfica não basta para incidir a causa de aumento do inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/0. É necessário que haja uma perfeita identificação de que a prática criminosa de tráfico, além de realizada nas imediações dos estabelecimentos elencados na referida lei, tenha em mira as pessoas que a circulam e estejam lá no momento. No presente caso, isso não ocorrerá. Confira-se a jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "A causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada, pois não basta para sua configuração que a posse de tóxico para tráfico tenha se verificado nas imediações de estabelecimentos de ensino ou creche, sendo de todo imprescindível a comprovação de que o insidioso comércio envolvia ao menos alguma das pessoas que frequentassem aqueles locais, o que não ocorreu no caso em tela". (Apelação nº 0000764-57.2017.8.26.0594, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 12 de novembro de 2018, relator MÁRIO DEVIENNE FERRAZ). Assim, não comprovada a direção do comércio espúrio àquele local, não há que se falar na aplicabilidade da agravante sob comento. Ademais, ao elencar uma circunstância fática como causa especial de aumento de pena, o legislador tem um fim a colimar, notadamente em razão da maior afronta que a conduta revela à sociedade. Na esteira de tal pensamento, ao elencar a causa de aumento de pena, quando a prática da traficância é realizada perto ou no interior de estabelecimento de ensino, beneficente, hospitalar ou de diversão pública, o legislador visou tratar com maior rigor a conduta do traficante que se estabelece perto ou no interior de tais estabelecimentos, sendo certo, que o mercador do entorpecente não se estabeleça ao lado de uma escola, entidade beneficente ou hospitalar, etc. por simples capricho. Assim faria, à evidência, mirando aqueles estabelecimentos como seu seio de fregueses. No mesmo sentido caminha o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo: "Apelação Defesa

Tráfico de Drogas Condenação Prova - Suficiência Réu preso em flagrante. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes. Desclassificação Artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Versão de porte para

consumo próprio que se mostrou inverossímil. Apreensão de 23 cápsulas de cocaína. Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros. Condenação mantida Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da circunstância atenuante da menoridade, sem repercussão na pena Súmula 231 d o S T J. Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Regime fechado que se impõe Recurso de Apelação Desprovido. Apelação Justiça Pública Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 Reconhecimento. Impossibilidade Local da prisão em flagrante em frente de entidades recreativa e hospitalar. A simples proximidade física com locais com tais instituições não justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Recurso de Apelação Desprovido". (TJ-SP-APL: 0000718- 66.2011.8.26.0404 SP, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro. Data de Julgamento: 18/09/2014, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/09/2014). Ainda: "APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. Pleito ministerial de incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06. "Entidade religiosa" não integrante do rol de estabelecimentos previstos no referido dispositivo. Circunstância de os fatos terem sido perpetrados nas imediações de outro estabelecimento não descrito na denúncia, a impossibilitar seu reconhecimento. Decisão irreparável. Recurso desprovido." (Ap. nº 00000707-56.2014.8.26.0299, Rel. Camilo Léllis, j. em 24.03.2015). Douto Julgador, concessa máxima venia, observe o horário em que ocorrera a prisão em flagrante, quer seja por volta das 07h10, e nesse caminhar, certamente a qualificadora supracitada não deve ser aplicada no caso em apreço. Do regime para cumprimento da pena / substituição da pena corpórea para penas restritivas de direitos. Uma vez reduzida a pena privativa de liberdade, deve-se proceder a análise da possibilidade de substituição da reprimenda corpórea por penas restritivas de direitos, e no tocante ao regime penitenciário, em atenção à modificação legislativa ocorrida por intermédio do controle de constitucionalidade das referidas normas. Assim, é que entendemos viável quanto à substituição da pena corporal para penas restritivas de direitos, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, declarou inconstitucional dispositivo legal da lei de Drogas que vedada a substituição. Não ainda, o Senado Federal, em observância a decisão do Supremo Tribunal Federal, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Não ainda, somente por amor aos debates, o Plenário do Excelso Pretório, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012, também incidentalmente a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, por entender que a norma contraria substancialmente Nossa Carta Política, mais especificamente ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI). Desta forma, diante das recentes decisões comentadas, requer se digne Vossa Excelência substituir uma eventual pena corpórea, por penas restritivas de direitos, atendendo assim à todos os requisitos legais. No que se refere ao regime inicial para cumprimento da pena, atendendo o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal e sopesando os critérios previstos no artigo 59, também do Código Penal, requer seja estabelecido o regime inicial para cumprimento de pena menos gravoso. Ademais, havendo a substituição da sanção corporal, por medidas restritivas de direitos, não mais se justifica a imposição do regime mais gravoso, isso porque, ao ser reconhecida a possibilidade de substituição da pena, busca-se justamente o não encarceramento do denunciado. Corrobora para o entendimento a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do referido HC nº 97.256/RS, em que se admitiu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do regime, a fim de que sejam observados os princípios a proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção penal, com a fixação de

regime prisional mais brando, compatível com a benesse concedida justamente para evitar o encarceramento" (STJ, HC nº 237.074/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.05.2012). "Nesse contexto, nas hipóteses em que se verificar a viabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em medida restritivas de direitos, não deve existir impedimento para a fixação do regime inicialmente aberto no cumprimento da pena" (STJ, HC 213.288/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.05.2012). "(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade como previsto no art. 33 do Código Penal (HC nº 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos" (STJ, HC nº 189.931/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012). Assim também entende o Excelso Pretório: "Ocorre que, em recentes julgados, esta Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com afastamento da regra do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o cumprimento no regime inicial fechado, para permitir-lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 33, II, C, do Código Penal". (STF, HC 109.343/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, v.u., j. 03.4.2012). Não ainda, ressaltamos que o crime pelo qual responde o denunciado, ser totalmente desprovido de violência e grave ameaça à pessoa. Nos crime em que imperam a violência e a grave ameaça à pessoa, assim como os crimes hediondos, certamente a benesse pleiteada deve ser vista com ressalvas, mas não é o caso denunciado. A este respeito também é devida observância à súmula 440 do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime. O E. TJSP tem seguido o mesmo entendimento em algumas de suas Câmaras Criminais. Exemplifica-se com arestos da 1ª, 10ª, 12ª, 13ª e 16ª Câmaras Criminais: TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DA TESE NO SENTIDO DA NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS, SE PRIVILEGIADO NOS MOLDES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO ESCOLHIDO PELO JUÍZO EM COERÊNCIA À QUANTIDADE DE PENA (01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO AGENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO. (Apelação nº 0002209-93.2017.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Diniz Fernando. j. 12.11.2018, Publ. 22.11.2018). TJSP-) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM COMPROVAM A DESTINAÇÃO DO TÓXICO À MERCANCIA E NÃO AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO ACERTADA. QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E HEDIONDEZ DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE FOI AFASTADA PELO PLENO DO E. STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000109-82.2018.8.26.0616, 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco Bruno. j. 08.11.2018, Publ. 12.11.2018). TJSP-) TRÁFICO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - CONFIGURAÇÃO - DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRIVILÉGIO - SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - MERA ILAÇÃO - QUANTIDADE POUCA EXPRESSIVA DE MACONHA - NEGATIVA INFUNDADA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS - CRITÉRIO - ART. 42 DO MESMO DIPLOMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO - HEDIONDEZ AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 118.533. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. (Apelação nº 0003964-83.2015.8.26.0322, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Vico Mañas. j. 05.12.2018, Publ. 07.12.2018). TJSP-) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL FECHADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ADMISSIBILIDADE - SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A MOTIVAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA, ÚNICA E

EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NÃO SÓ PORQUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECLAROU A - INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL DISPOSITIVO, MAS TAMBÉM PORQUE O PRETÓRIO EXCELSO, NO HABEAS CORPUS Nº 118533/MS, AFASTOU A NATUREZA HEDIONDA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". ALIÁS, HÁ ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO, ACERCA DA NÃO HEDIONDEZ DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO", SEGUIDA POR ESTA COLENDIA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES OU VINCULANTE DO R. DECISUM DAQUELA CORTE CONSTITUCIONAL, É DE BOM ALVITRE QUE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IGUALDADE, O ENTENDIMENTO EXTERNADO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 118.533 SEJA ADOTADO POR TODOS OS JUÍZES E TRIBUNAIS BRASILEIROS, EVITANDO-SE, COM ISSO, DECISÕES EM SENTIDOS OPOSTOS ACERCA DA MESMA MATÉRIA E QUE SOMENTE AQUELES ACUSADOS QUE POSSUAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA GALGAR TODAS AS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM BENEFICIADOS PELOS EFEITOS DECORRENTES DA NOVA ORIENTAÇÃO DE QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO POSSUI CARÁTER HEDIONDO. DE RESTO, CABÍVEL, EXCEPCIONALMENTE, O REGIME ABERTO EM FACE DO QUANTUM DA PENA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus nº 2215577-73.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Moreira da Silva. j. 25.10.2018, Publ. 30.10.2018). TJSP-) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INDEFERIMENTO - CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - CÁLCULO QUE CONSIDEROU A HEDIONDEZ DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - RECENTE JULGAMENTO DO STF QUE ENTENDEU NÃO SER HEDIONDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - HC 118533 - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DO STF - SÚMULA 512 DO STJ CANCELADA - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DETENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - AGRAVO PROVIDO. (Agravado de Execução Penal nº 0013382-10.2018.8.26.0041, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Newton Neves. j. 09.11.2018, Publ. 09.11.2018). No presente caso, cedo que o regime a ser eleito deve ser o regime aberto, atrelado ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, combinado com as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, o qual, antecipadamente prequestionamos a matéria, objetivando a interposição de eventuais recursos às Instâncias Superiores. Do direito de o réu recorrer em liberdade. Requer se digne Vossa Excelência, conceder ao denunciado, em caso de condenação, o direito de recorrer em liberdade, eis que não mais presentes os requisitos legais para fundamentar uma custódia cautelar. Ex positis, requer se digne Vossa Excelência, nos termos da legislação processual penal, julgar parcialmente procedente a presente ação penal, aplicando-se as teses defensivas, acima requeridas, elegendo o regime aberto para cumprimento da sanção corpórea, com conversão para penas restritivas de direito, por ser a mais Lídima Justiça. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de WESLEN MORAIS DE SOUZA (nascido em 18/03/2002), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 10/12/2021, por volta das 07h10, na Rua Florentino do Nascimento, altura do nº 280, Jardim Nova América, neste Município e Comarca de Suzano, guardaria e teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 32 porções de maconha (77,21g), 11 porções de cocaína (5,55g), 16 porções de crack (2,22g) e 03 frascos de lança-perfume, além de R\$ 14,00 em espécie.

Em 11/12/2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 57/59).

Em 11/02/2022, foi apresentado aditamento à denúncia, para incluir a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois os fatos teriam ocorrido nas imediações da Congregação Brasil Cristão, da Escola Municipal Isaias Martinelli Gama e do salão de festas Chácara Sonhos de Noiva (fls. 124).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia (fls. 134/136).

Em 17/05/2022, foi recebida a denúncia e o aditamento e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 140/141).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia e do aditamento.

Por sua vez, a Defesa requer a consideração das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, a fixação da pena no mínimo legal, do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 16/17), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 40/43) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 72/74 e 87/89).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Ricardo Alexandre Pinheiro declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes, quando viu o Réu mexendo em um monte de areia, coberto por um plástico preto. Ao avistar a viatura, ele tentou sair do local, disfarçando, o que motivou a abordagem. Revistado, com o Réu foram encontrados um celular e um pino de crack. Feita busca no monte de areia, foi achada uma sacola, com diversos entorpecentes, de variadas espécies, que não se recorda bem quais eram. Indagado, o Réu disse que estava guardando as drogas para as entregar, posteriormente, a um adolescente, que as comercializaria. Não havia mais ninguém próximo ao Réu quando da abordagem.

O policial militar Paulo Cesar Diniz Arrais prestou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório, o Réu confessou a imputação, nos exatos termos da denúncia.

Em delegacia, confessou a prática delitiva, dizendo que entregaria as drogas ao "vapor" (fls. 12).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, guardava e tinha em depósito droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

A confissão judicial do Réu foi integralmente confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, colhidos nesta audiência, bem como por todas as provas colhidas na fase policial, não havendo qualquer divergência a respeito da dinâmica dos fatos, que é exatamente a descrito na denúncia e em seus posteriores aditamentos.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que os fatos ocorreram a 20 metros de distância de uma igreja, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 106/109. Não se pode, porém, dizer que os fatos ocorreram nas imediações dos demais pontos apontados no laudo e pelo Ministério Público, pois distância superior a 150m (um quarteirão e meio, aproximadamente) não pode ser

considerada "imediatação".

Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, eis que o Réu não ostenta bons antecedentes (fls. 45/46). Ele tem uma condenação não transitada em julgado, que não configura reincidência, tampouco maus antecedentes, mas sim antecedentes neutros. Isso porque os antecedentes, como todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, podem ser favoráveis, contrários ou neutros. A lei prevê expressamente que a causa de diminuição de pena só se aplica aos condenados com bons antecedentes, o que não é o caso do Réu, razão pela qual inaplicável ao caso concreto.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas quatro variedades, entre elas crack e cocaína, especialmente viciantes e danosas à saúde pública. Por outro lado, a quantidade é razoável, sendo essa circunstância judicial neutra. Conforme já exposto, o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior, ainda não transitada em julgado (fls. 45/46). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em $\frac{1}{4}$ acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes e verifica-se as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, reduzo a pena base em $\frac{1}{5}$, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Como os fatos foram praticados nas imediações de uma igreja, apenas, aumento a pena provisória em $\frac{1}{6}$, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias